

1501852-91.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2257039/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 20372736 - 03º D.P. DIADEMA, 3293/21/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2257039 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501852-91.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001362

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2257039/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 20372736 - 03º D.P. DIADEMA, 3293/21/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2257039 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

FERNANDO SILVA, qualificado às fls. 05 e 17/18, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 21h30, na Passagem Samuel, altura do nº 10, bairro do Casa Grande, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 5 embalagens plásticas contendo 1,95g da droga cocaína e 72 embalagens plásticas contendo 30,32g da droga maconha, conforme auto de apreensão e

exibição de fls. 16 e laudo de constatação provisória de fls.22/23, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl.52/54) o réu foi notificado (fl. 86), tendo constituído Advogado particular, quem ofertou defesa inicial às fls. 91/95. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 11/11/2021 (fls.106/107) e certificada a citação positiva do Réu a fl. 138.

Na primeira audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvida uma testemunha, indeferido o pedido de liberdade provisória do réu e redesignada a audiência para oitiva do policial Diego, doente na data. Nesta audiência, em continuação, foi ouvido esse policial e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante dos maus antecedentes do réu, discordando com a redução da pena, e de sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem direito de recurso em liberdade, e sim a perda do numerário apreendido.

Já o d. Advogado reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com o redutor da pena e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, e possibilidade de recurso em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 16, nos laudos de constatação e definitivo (respectivamente às fls.19/21 e 125/127), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls. 03/04) estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, onde costumeiramente ocorre traficância de entorpecentes, e em dado momento receberam denúncia de um transeunte que forneceu as características físicas de pessoa que estaria traficando drogas na Passagem Samuel. Ao adentrarem à tal viela, avistaram a pessoa do ora indiciado Fernando Silva, o qual estava recebendo algo que parecia dinheiro de uma pessoa desconhecida. Tentaram abordar o indiciado e o desconhecido, porém este segundo correu e não foi alcançado, tomando rumo ignorado. Quanto ao indiciado, este tinha ao seu lado uma sacola com invólucros contendo substâncias aparentemente entorpecentes, e próximo a ele, haviam outros invólucros plásticos contendo substâncias aparentemente entorpecentes que estavam expostos para "venda", sobre uma mureta. Também havia em poder do indiciado a quantia de R\$ 21,00 em espécie. Ele admitiu que traficava drogas naquele local, mas não informou maiores detalhes. Desta forma, deram voz de prisão e o conduziram para este Plantão.

Sob o crivo do contraditório o policial Jefferson Novaes confirmou que estavam em patrulhamento e um transeunte deu a descrição de um indivíduo, homem, com certas vestes, que estaria vendendo drogas na viela. Entraram na viela para averiguar a situação informada. Ao chegarem lá, o réu estava sentado próximo a uma mureta recebendo algo de uma pessoa, possivelmente dinheiro. Os dois rapazes correram. Só conseguiram abordar o réu, e com ele havia pouca quantidade de droga. Ao lado dele,

na mureta, estava o restante dos entorpecentes. Indagado, respondeu que morava ali próximo e depois confirmou já ter problemas com a Justiça e que realmente estava no ponto, traficando. Reconhece o réu. Mandaram ele recolher as drogas que ele tinha posto na mureta, enfileirados, e coloca-las numa sacola. Foi apreendida uma quantia em dinheiro proveniente, segundo o réu, do "trampo" dele, mas ele tinha dito que estava desempregado. Pararam a viatura na entrada da viela. Seu parceiro era o motorista e quem fica de olho na viatura. Por isso desembarcou primeiro e seu parceiro veio atrás de si, quando viu que tinha abordado o réu. Mostrada a foto de fl. 144, reconhece a viela como sendo o local da abordagem, no fundo, mas não se recorda dos demais pontos fotografados nas folhas seguintes.

O miliciano Dhiego Nery reiterou em juízo que a equipe estava em patrulhamento e um indivíduo passou as características do indivíduo. Viu um rapaz entregando algo para o réu e esse rapaz correu, mas o acusado foi detido e com ele uma sacola com as drogas e outras expostas em cima de uma mureta que pediram para ele colocar dentro da sacola. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu no local, uma biqueira estabelecida. O dinheiro e as drogas foram apreendidas. Questionado o réu, ele respondeu que morava lá e que já tinha sido preso, mas não lembra o artigo. Estava pilotando a viatura, de modo que seu parceiro desembarcou primeiro. Fez a manobra, estacionou a viatura, a trancou, e seguiu seu parceiro. Não reconhece o local que consta da foto de fl. 144, e um pouco da de fl. 145.

O réu, em solo policial (fl.05) respondeu que estava sentado no meio fio da calçada, momento em que chegaram policiais militares naquele local, e diversas pessoas que estavam na viela saíram correndo. Em seguida foi abordado, sendo que os policiais mandaram o interrogando recolher no chão algumas substâncias aparentemente entorpecentes, e colocar em uma sacola, sendo que em seguida foi encaminhado para esta Delegacia. Esclarece que é usuário de cocaína, e que reside próximo ao local, mas nega qualquer envolvimento com a atividade de tráfico de entorpecentes.

Em juízo o acusado alegou que mora perto de lá e frequenta o local. Era noite. Viu o policial descendo. Passou por si e foi para o fundo da viela onde tinham uns rapazes, que correram, e ele foi atrás. Depois de dois minutos ele veio com uma sacola perguntando de quem eram as drogas e como não sabia, teria que assumir a bronca. Não conhecia os policiais até então. Estava sentado, mexendo no celular e no terreno baldio ao lado, fica brincando com seu filho e onde as crianças brincam. Não disse ao escrivão nem ao delegado de polícia que teve que pegar drogas do chão e teve que colocar na sacola. Já foi viciado, mas não é mais, negando ter dito ser viciado, pois não lhe ouviram no DP. Tinha discutido com sua esposa e foi para o escadão, e não estava lá nem dois minutos e os policiais chegaram. Já foi processado o roubo. Estava trabalhando como técnico autônomo de antena, para sua clientela. Alega que o policial Fernando não entrou na viela. Estava sentado na escada fotografada a fl. 145, o policial passou por si e desceu as escadas e depois voltou.

Logo, depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque ele trouxe outra versão nesta audiência, ou seja, de que teria discutido com sua esposa e foi se sentar na escadaria para esfriar a cabeça, sendo preso cerca de dois minutos depois, quando o policial já tinha passado por si e retornado com uma sacola contendo drogas, que teve que assumir, negando tenha que ter catado drogas do chão, negando também estar na companhia de outras pessoas, não sabendo explicar o motivo de não ter arrolado sua esposa a confirmar seu álibi.

Nem se alegue haver apenas os relatos dos policiais, pois é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A

defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Ademais, houve uma denúncia anônima dando conta das características do réu como sendo o traficante do local, ponto já conhecido por venda de drogas, denúncia esta que restou verídica após a incursão policial. E tão pouco se alegue que o policial Dhiego não tenha adentrado a viela nem participado da detenção do réu porque como ele mesmo explicou, era o motorista da viatura e quem desembarcou e adentrou a viela primeiro foi seu parceiro, tendo ele ido após manobrar, estacionar, fechar a viatura, chegando num segundo momento, portanto.

Ainda, foi presenciado ato de comércio entre o réu e o indivíduo que correu. Mesmo assim não fosse, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e transportar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 82), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, assim como a quantidade do narcótico apreendido que não reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, mas diante dos maus antecedentes do réu (condenação definitiva na comarca de Paulínia, em 2019, por crime de roubo- fl. 34) fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal: 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem observadas, pois o réu não confessou o crime em nenhuma das suas duas negativas de autoria diferentes, restando a pena inalterada nessa etapa.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja primário (fls.67/71), mas considerados os maus antecedentes criminais (fl. 34) além do numerário apreendido (R\$21,00 - fl. 82) proveniente da venda de drogas, já que inexistente prova de que tenha sido de um trabalho lícito do réu, pois a Defesa não provou que ele fosse técnico de antena, trabalhando para clientes próprios, tudo a demonstrar maior envolvimento com o crime e com a traficância ilícita, opto pelo percentual de 1/3, totalizando 03 anos e 08 meses de reclusão e 366 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

O quantum da condenação, a quantidade de pena, o fato do crime não ter sido praticado com violência nem grave ameaça à pessoa, a quantidade de droga que não reputo alta assim como a maior parte dela tratar-se de maconha, de menor poder viciante e menos maléfico à saúde do usuário, face aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o regime prisional semiaberto, consoante disposto nos artigos 33, do Código Penal.

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, dado que o artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas,

que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Portanto, traficantes de substâncias entorpecentes, seja de pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição considerável. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalte-se que uma das exigências previstas no art. 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa. Portanto, não é socialmente recomendável tal benesse diante da elevada culpabilidade do traficante, especialmente para não potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade, por violar mais intensamente o bem jurídico tutelado, e dado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem da prática de delitos de tráfico um verdadeiro meio de vida.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por já ter maus antecedentes, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz

natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Ademais, o réu está preso há cinco meses.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra FERNANDO SILVA, qualificado às fls. 05 e 17/18, como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 366 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. O recomendo no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, por ora, ante a concessão de justiça gratuita (fl. 107).

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fl. 82), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA